

제61회 변리사 시험 디자인보호법 해설

By. 한빛 디자인보호법 강사진

안녕하세요.

한빛 디자인보호법 강사 정다운입니다.

시험 마지막 과목인 선택과목이 끝날 때까지 가장 치열한 48시간을 보내고 오신 모든 수험생 여러분 정말 고생 많으셨습니다. 그간의 노력과 절제와 기다림이 부디 좋은 결과로 이어질 수 있게 기원하겠습니다. 잘 아시겠지만 본 해설은 참고적으로 한번 내용을 재확인해보는 용도로만 생각하시고, 지나간 시험을 돌아보며 혹여나 위축되거나 괴로워하지 않으셨으면 합니다. 일단은 당분간 스스로에게 충분한 격려를 주면서 휴식할 수 있는 시간이 되셨으면 하는 마음입니다.

올해 변리사 2차 디자인보호법 시험은 전형적인 출제 경향과는 다른 면이 많았기 때문에 체감 난이도가 높았을 것으로 예상됩니다. 대표적인 대법원 판례 사례나 심사기준 등 디자인보호법에서 가장 중점적으로 대비하는 내용에서는 거의 출제되지 않고, 절차 및 심판 등에 관한 법조문과 판례 법리가 다수 출제되었습니다. 추후 디자인보호법 2차 공부를 할 수험생분들도 이러한 경향을 디자인보호법 2차 시험의 일반적인 경향으로 파악하실 필요는 없고, 전형적인 중요 논점들을 대비하면서 법조문과 타법상의 판례를 활용하여 문제를 풀이할 수 있다는 가능성을 늘 생각해두시면 될 것 같습니다.

다시 강의실에서 뵙는 대신 합격자 박람회에서 뵈 수 있으면 좋겠습니다. 수고 하셨습니다. 감사합니다.

2024. 07. 28.

정다운 드림.

*본 해설 자료는 강사진이 작성한 견해에 불과하므로 이의신청의 근거가 될 수 없습니다.

[문제 1]

문제 요약 : 甲과 B사의 공동창작에 의하여 디자인 X 완성 후, 甲이 X를 단독으로 디자인등록출원 하였고 출원 후 C사로 출원인 변경을 완료함으로써 C사가 디자인권자로서 디자인등록됨. 이후, 乙이 C사에게 디자인권을 양수(이전)하였음에 반해, 丙은 B사로부터 포괄양수(일반승계)를 받아 Y 제품을 제조·판매함.
(문제에서 등록디자인 X과 디자인 Y 제품 이미지가 제시되었는데, 서로 유사한 디자인으로 볼 수 있을 정도로 판단됨)

I. 설문 (1) : 乙과 丙이 디자인보호법상 취할 수 있는 조치 (15점)

1. 乙의 조치

(1) 필요한 조치 - 乙의 디자인권 이전 등록

- C사의 출원인 변경신고(제57조제3항) 이후 디자인등록 되어 C사가 권리자
- 디자인권 이전은 등록이 효력발생요건(제98조제1항제1호)이므로, 乙이 이전 등록하지 않으면 C사가 여전히 권리자. 조치를 위해 乙로 디자인권 이전 등록 필요

(2) 丙에 대해 가능한 조치 - 침해에 따른 권리행사

1) 丙의 실시가 X 디자인권 침해인지 여부

- 유효한 디자인권 존속 : 출원인 적격 무효사유가 있으나, 무효심결 확정으로 무효되지는 않았으므로(디자인권 공정력) 유효한 권리
- 정당한 권원 : ① 乙 명의로 등록된 디자인권에 대해 丙의 지분은 없음. / ② 甲이 B사의 종업원이 아니었으므로 직무디자인에 의한 법정실시권 발생 사안도 아님
- 보호범위 내 업으로서 실시 : 디자인 X, Y 전체적으로 유사하여 보호범위 내 실시(제92조)

2) 침해 주장에 따른 조치 - 침해 경고, 침해금지청구 등 민형사상 조치 가능

2. 丙의 조치

(1) 필요한 조치 - 승계 사실 신고

- 최초로 甲, B사가 디자인등록 받을 수 있는 권리를 공유하는지 : B사는 자연인이 아니므로 창작자로 인정되기 어려우나, 설문 취지상 B사의 직원 등이 창작하여 B사가 디자인등록 받을 수 있는 권리의 지분을 승계한 것으로 해석 타당
- 丙의 조치 : 디자인 등록을 받을 수 있는 권리의 포괄승계 효력은 승계 시 발생하나, 지체 없이 승계 사실 신고해야 함(제57조제4항)

(2) 乙의 디자인권에 대해 가능한 조치

1) 丙의 지분 양도 요구

2) 무효심판 청구 - 제39조 공동출원 규정 위반을 무효사유로 등록디자인 X에 대한 심판 청구 가능.

- ① 이때 丙 지분비율 만큼의 무효가 아닌 전체 디자인권 무효를 청구할 것 / ② 디자인등록 받을 수 있는 권리를 갖는 자로서 무효심판 청구인적격을 위한 이해관계 인정

3) 정당권리자 출원(제45조) - 무효심판에 의해 심결이 있는 경우, 乙과 丙 공동출원인으로 한 출원 시 C사의 최초 출원일로 출원일 소급 적용 가능

4) C사에 대한 지분 양도의 효력 다툼 - 디자인등록 받을 수 있는 권리의 공유자인 B사 또는 丙의 동의 없이 이전되었으므로 공유자 동의 없는 지분 양도임을 다툴 수 있음(제54조제3항)

II. 설문 (2) : 乙과 丙이 소송과정에서 할 수 있는 주장 (5점)

1. 甲과 B사의 계약의 성질 및 효력

(1) 부제소 합의

(2) 부제소 합의가 유효하기 위한 요건 - 특정한 법률관계에 관한 것 / 합의 당시 당사자가 예상할 수 있는 상황 / 의사표시의 하자가 없을 것 / 강행법규 위반 아닐 것

2. 乙의 주장

- 특정한 법률관계가 아닌 등록되지 않은 모든 지식재산권에 관한 부제소 합의이므로 무효 타당.
- 乙이 제기하는 침해 등에 관한 소는 적법 주장

3. 丙의 주장

- 디자인등록출원 후 합의이므로 충분히 예상할 수 있었던 상황으로서 유효한 합의
- 침해에 관한 소는 부적법하여 각하됨이 타당 주장

III. 설문 (3) : 출원 전 공지디자인 결합에 의한 용이창작 무효 주장 (10점)

1. 소문 1) - 권리남용 판례 입장

(1) 권리남용의 의의

(2) 대법원 판례의 태도 - (2016다219150) 출원 전 공지디자인의 결합에 의한 용이창작으로 창작비용이 성 무효사유 명백한 경우, 그 디자인권에 기한 권리행사는 권리남용으로서 허용되지 않음.

(3) 설문의 경우 - 등록디자인 X가 공지디자인 P와 Q의 결합에 의해 용이하게 창작 가능한 경우 제33 조제2항 무효사유 명백하여 권리남용

2. 소문 2) - 법원의 용이창작여부 심리판단 거부

(1) 대법원 판례의 태도 - (2016다219150) 권리남용 항변이 있는 경우 그 판단 전제로서 용이창작 심리판단 가능

(2) 설문의 경우 - 공지디자인 P, Q 각각 또는 결합으로부터 디자인 X가 용이창작 가능한지 판단

[문제 2]

I. 설문 (1) : 甲이 이해관계인인지 여부 (5점)

1. 무효심판 청구인 적격 (제121조제1항) - 이해관계인 또는 심사관
2. 판례의 태도 - ① 특허제품을 제조·판매하고 있는 자는 권리의 소멸에 이해관계 있음 (등록디자인과 동일·유사 범위의 디자인을 제조·판매하고 있는 자도 이해관계 있음 해석) / ② 특허권자(디자인권자)로부터 침해 경고를 받는 등 권리의 대항을 받은 자 이해관계 있음
3. 설문의 경우 - 甲은 실시 중 & 침해 경고 서면 받은 자로서 등록디자인 B에 대해 이해관계 있음

II. 설문 (2) : 공업상 이용가능성 (15점)

1. 공업상 이용 가능성의 의미
 - (1) 공업상 이용 가능성(제33조제1항) 의의 및 취지
 - (2) 요건 - 공업적 생산방법 / 동일 물품의 양산 가능성 (판례 및 심사기준 일반론)
 - (3) 유형 - ① 공업적 생산방법으로 양산 불가능한 디자인 (자연물 / 순수미술분야 등) ② 디자인의 표현이 구체적이지 않은 경우(도면 기재불비)
2. 등록디자인 B의 제33조제1항 무효사유 인정 가부
 - (1) 구체성 흠결의 유형 - 디자인의 요지를 파악할 수 없는 경우 등 일반론
 - (2) 판례의 태도 - (2004후2123) 도면 내 불일치가 있더라도 통상의 디자이너가 경험칙에 의하여 디자인의 요지를 충분히 특정할 수 있는 경우 위반 X
 - (3) 설문의 경우 - 불일치한 부분을 고려했을 때 디자인 요지 파악이 불가능한 정도의 불일치가 있는 경우에만 제33조제1항 무효사유로 무효 가능

[문제 3]

I. 설문 (1) : 권리범위확인심판 선사용권 판단 (5점)

1. 권리범위확인심판의 의의 및 성질(제122조)

2. 판례의 태도 - 선사용권 유무는 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권 존부 심리판단은 허용되지 않음

3. 설문의 경우 - 디자인권에 관한 권리범위확인심판도 동일 해석. 乙의 선사용권 존부 판단은 허용X

II. 설문 (2) : 심결취소소송 주장 (15점)

1. 심결취소소송에서 새로운 주장 가부

(1) 심결취소소송의 위법여부 판단 시점 - 심결 시(2018.6.7.) 기준. / 등록디자인 A의 출원 전 사실 관계는 심결 시 이미 있던 사실관계이므로 판단 가능

(2) 심결취소소송의 심리범위 - 판례는 원칙적으로 무제한설 입장으로서는 심결취소소송에서 새로운 공격 방어방법 주장 가능 입장 / 예외적으로 거절결정불복심판 등 결정계 심판은 제한설 입장을 취함

(3) 설문의 경우 - 권리범위확인심판이므로 무제한설. / 출원 전 공개된 선행디자인에 따른 항변(방어방법)이므로 주장 가능

2. 무효의 항변

(1) 판례의 태도 - 출원 전 공지 등이 된 디자인과 동일유사한 경우 등록무효 심결이 없어도 권리범위 인정할 수 없음 (신규성 무효사유 명백 시 권리범위 부정 가능)

(2) 설문의 경우 - 공지된 선행디자인 X가 등록디자인 A와 유사하여 신규성 무효사유 명백 주장

3. 자유실시디자인의 항변

(1) 판례의 태도 - 확인대상디자인이 등록디자인 출원 전 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 경우 등록디자인과 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않음 (공지디자인으로부터 용이창작 범위 시 자유실시 항변 가능)

(2) 설문의 경우 - 공지된 선행디자인 X로부터 디자인 B가 쉽게 실시 가능하여 자유실시 영역 주장

4. 권리남용의 항변 가부

- 판례는 권리범위확인심판에서 권리남용 여부는 심리판단의 허용되지 않는다는 입장이므로 불가능

III. 설문 (3) : 심결 취소 후속 절차 (10점)

1. 심결 취소 후 특허심판원 환송(제169조제2항)

- 특허심판원으로 환송되며, 심판관은 심결 취소 판결 확정 시 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.

2. 심결취소소송의 기속력(제169조제3항)

- 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 기 사건에 대해 심판원을 기속한다. / 취소의 이유가 된 사실상, 법률상 판단에 기초하여 심판원의 판단이 이루어져야 함.

3. 설문의 경우

- “권리범위에 속한다는 심결의 취소”가 기속력을 가지므로, 심결취소소송에서 무효의 항변, 자유실시디자인의 항변 등이 받아들여진 것이라면 특허심판원에서도 이와 배치되는 판단을 할 수 없음
- 환송된 특허심판원에서 권리범위확인심판은 심결 시 새로운 사실관계 발생하지 않은 한, 기각심결 내려야 함

[문제 4]

Ⅰ. 설문 (1) : 관련디자인과 유사디자인 (7점)

1. 관련디자인 제도의 의의 및 도입 취지(제35조)

- 디자인 출원 이후 개량, 변형한 유사디자인을 등록할 수 있도록 하여 출원인 권리보호 강화, 유사 영역 디자인의 모방과 침해 미연에 방지
- 2016년 개정법에서 종전의 유사디자인 제도 폐지, 관련디자인 제도 도입

2. 구법상의 유사디자인 제도와 차이점

- (1) 공통점 : 자기의 기본디자인과 유사한 범위의 디자인을 등록 가능 (선출원주의 적용 예외) / 존속기간은 기본디자인의 출원일을 기산점으로 하여 함께 만료함.
- (2) 차이점 : 권리의 독립성
 - 유사디자인의 디자인권은 그 기본디자인의 디자인권과 합체한다(구법 제42조). (권리범위 해석에 관하여 견해 대립함(확안설, 확장설, 결과확장설))
 - 다만, 관련디자인은 독립적인 권리범위가 인정되는 별개의 권리임

Ⅱ. 설문 (2) : 기본디자인 소멸 시 (6점)

1. 관련디자인 출원의 객체적 요건 (제35조제1항)

- 기본디자인의 출원 또는 등록은 관련디자인 등록여부결정 시에 유효하게 존속해야 함
- 관련디자인 출원 후 기본디자인권이 소멸하거나, 기본디자인 출원이 무효, 취하 등이 된 경우 그 관련디자인은 제35조제1항 거절이유 통지. / 심사관은 제48조제2항에 따라 단독디자인으로 보정 권고 가능 (디자인 심사기준)
 - 최근 개정법은 관련디자인 설정등록 시 기본디자인의 디자인권이 설정등록되어 있지 않거나, 기본디자인의 디자인권이 취소, 포기 등으로 소멸한 경우 관련디자인으로 등록받을 수 없다(제35조제1항 단서)라는 규정 입법.

2. 관련디자인 등록 가능 여부

- 기본디자인권 또는 출원 소멸 시 제35조제1항에 의해 관련디자인으로는 등록 불가능
- 甲이 디자인 B에 관한 출원을 단독의 디자인으로 보정(제48조제2항) 시 등록 가능

Ⅲ. 설문 (3) : 동일자 별개 출원 (7점)

1. 선출원주의의 적용

(1) 유사한 디자인의 동일자 출원의 취급(제46조제2항) : 특허청장이 기간 정하여 협의 명령

(2) 동일인 출원의 경우 : 출원인이 선택한 하나의 디자인만 등록 가능 / 기간 내 선택 신고가 없는 경우 양 출원 모두 거절 / 관련디자인 변경 시 등록가능 취지 함께 통지

2. 설문의 경우

- 디자인 A, 디자인 B는 좌측판부이 반원형홈 포함여부 및 파이프 삽입홈부의 형상 차이로 세부적인 점에만 차이가 있는 유사한 디자인

- 유사한 2 이상의 디자인 동일자 출원이므로 제46조제2항 적용, 기간 정하여 선택 명령

- 甲이 디자인 A 또는 B 중 하나를 관련디자인으로 변경하는 보정 시 둘 다 등록